

数据国际治理:人权、安全和主权的耦合与差序

吴晓丹

(中央财经大学 法学院,北京 100081)

[摘要] 规制数据跨境流动不单是数字贸易话题,更是数据国际法治和网络空间国际治理的重要组成部分。不完善、不合理的差异化、碎片化规则导致跨境数据流动面临诸多障碍,国际摩擦纷争不断,根本原因在于各国在人权、安全和主权的概念内涵、关联关系以及有关价值取向、治理理念和规制方法上存在差异、竞争甚至对抗。因此,只有整体性思考人权、安全和主权在国际和国内层面的耦合关系,确立回应数据治理特殊需求和富有弹性的差异性秩序,方能构建协调、统一的全球数据治理框架。对中国而言,须击破美欧有关人权、主权、安全的双重标准和偏颇叙事,统筹推进国内法治与涉外法治,以多元均衡的中国方案推进人权、安全和主权的耦合关联以及数据国际治理的差序构建。

[关键词] 跨境数据流动;隐私保护;国家安全;数据主权;数据本地化;数据国际治理

一、问题的提出

数据^①具有突出的经济属性和赋能作用,是个人隐私和基本权利保护对象,作为战略资源还涉及国家安全和主权议题,因此被称为“新石油”,即最重要和最富争议的地缘政治资源。数据跨境流动是数字经济发展的必要条件,也是21世纪全球化的重要标志。常见情形有:依靠数据流动完成跨境交易的电子商务;跨国企业为遵循税务调查等合规要求传输数据;企业考量成本收益将数据处理任务委托于境外机构;企业利用云技术进行备份时,数据于异国服务器之间移转;尽管数据尚未跨越国界,但能被第三国主体访问或调取。鉴于网络空间的物理无边界性和数据的频繁跨境流转,国际治理是数据治理的应有之义。在早期讨论难有定论的背景下^{[1]198},全球层面国际组织的诸番努力事倍功半。1980年,经济合作与发展组织(OECD)通过的《个人数据隐私和跨境数据流动保护指南》以下简称《保护指南》等达成有限的原则性共识;20多年来世界贸易组织(WTO)电子商务谈判的进展乏善可陈;2005年,联合国贸易法委员会(UNCITRAL)达成《联合国国际合同使用电子通信公约》,至今只有18个当事国,近年将工作重点转移到示范法。与全球治理发展滞后形成鲜明对比

[收稿日期] 2024-09-04

[本刊网址·在线杂志] <http://www.zjujournals.com/soc>

[在线优先出版日期] 2025-08-02

[网络连续型出版物号] CN 33-6000/C

[基金项目] 国家社会科学基金一般项目(19BFX206)

[作者简介] 吴晓丹(<https://orcid.org/0000-0002-1498-0666>),女,中央财经大学法学院副教授,法学博士,主要从事国际法学研究。

① 在中文语境中,信息与数据、隐私的内涵有所不同,本文沿袭域外表述未加区分,除非有特别说明。

的是,各国数据立法活跃,80%的国家已经或正在为数据和隐私保护立法^①。出于保护本国产业、弥补数字鸿沟^②、保护个人信息和维护国家安全与数据主权等目的,各国均设定了不同程度和范围的限制性和禁止性跨境传输要求。数据的多元属性及相关问题的复杂性导致各国在规制理念与路径方法上存在重大分歧,主要国家和地区在立法上呈现一定程度的差异化甚至对抗性。欧盟^③主推以人权为基础的数据保护标准,要求他国向欧盟的标准看齐靠拢,美国则基于低水平保护机制使个人信息方便向美国集聚。欧盟重视数据保护的规制主义统一式立法与美国强调自由主义的分散式立法(包括联邦法和州立法)引发欧美关于数据传输的《安全港协议》《隐私盾协议》的废止^[2]。欧美的做法使得其他国家采取诸多举措,防范美国对全球数据的收集监控和欧盟的过度监管给经济发展和国家安全带来的巨大威胁。其中,中国、俄罗斯、印度等国秉承本地化理念关注国家和公众利益,或以全面禁止数据跨境流动为原则,或有条件允许数据跨境流动,美西方对此表达诸多不满和批评。在全球层面进展有限的情况下,双边和区域自由贸易协定成为国际规则的主要发展方式,近年主要区域自由贸易协定都涉及规范数字贸易和减少数据流动障碍的专门条款甚至章节,如2018年生效的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP),2020年生效的《美国—墨西哥—加拿大协定》(USMCA)和《数字经济伙伴关系协定》(DEPA),以及2022年生效的东盟《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)。以内国价值取向和国家利益为基础,美欧的国际协调努力形成了“俱乐部化”规制集团,这是数据国际治理分散化、碎片化和WTO电子商务谈判不顺的重要原因。国内立法、双边和区域自由贸易协定无法确立系统的国际治理体系,阻碍了经济要素流动,导致贸易、投资纠纷和争端频发,必须重回全球层面。规则竞争是竞争的最高形态,已经成为国际竞争的主要方式,但也为协调构建普遍接受的数字贸易规则体系提供了机遇。总体而言,欧盟、美国和中国的数据法成为最主要的立法冲突形态,使得三大主体产生了一定的矛盾,也是协调构建全球数据治理框架的基本面。数据的全球治理不限于传统的经贸领域,将其简单视为国际经济秩序问题会忽视其与个人权利保护、国家安全、数据主权等更宏大问题的复杂关联。跨境数据流动规制从开始就关乎国内法与国际法的内外联动,这是美国和欧盟以国内政策与法律塑造和影响国际治理发展的关键。因此,应突破国内数据法和国际经济法的窠臼,对人权、安全和主权的耦合关系作出整体性和关联性思考,也鉴于各国人权、安全和主权的价值取向和规制理念存在巨大差别,以多元均衡理念确立富有弹性的差异性秩序,方能有效回应数据国际治理的特殊需求,构建协调、统一的全球数据治理框架。

我国重视数字经济国际合作,积极探索跨境数据管理模式。2022年12月,中共中央、国务院发布的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》指出:“深化开放合作,实现互利共赢。积极参与数据跨境流动国际规则制定,探索加入区域性国际数据跨境流动制度安排。推动数据跨境流动双边多边协商,推进建立互利互惠的规则等制度安排。鼓励探索数据跨境流动与合作的新途径新模式。”^④2023年发布的《“一带一路”数字经济国际合作北京倡议》为数字经济国际合作搭建了新平台。2024年国务院办公厅印发的《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》和中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《数字贸易改革创新发展的意见》都明确全面参与WTO、亚太经济合作组织(APEC)、二十国集团等有关谈判,积极推进高标准经贸协议谈判和实施,健全数据跨境流动规则。完善数据跨境流动国内和国际规则不仅是中国数字经济发展的的重要支撑,也是中国在数字经济国际竞争与合作以及数据国际治理中建立优势的关键。本文旨在击破美

① UN Trade and Development Global Cyberlaw Tracker, 2021-12-14, <https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide>, 2025-01-10.

② 数字鸿沟主要表现为网络技术差距带来的各国在教育与人才培养、基础设施建设以及财富创造能力上的差异。

③ 欧盟是由27个成员国组成的区域一体化组织,但规范数据跨境流动的一体化程度颇高,故本文将其纳入国家序列讨论。

④ https://www.gov.cn/zhengce/2022-12/19/content_5732695.htm.

欧有关人权、主权、安全的双重标准和偏颇叙事,为完善跨境数据流动国内制度和构建数据全球治理的中国方案提供智识。

二、人权属性:数据国际治理和中国叙事的基础

各国基本认同数据的隐私属性。在全球层面确立协调统一的国际规则,达成基本保护标准的目标是让国内监管者相信数据离开其管辖并不会破坏本国监管目标的实现^{[3]244}。但各国保护的价值观和具体方式差异悬殊,这种差异不仅反映了不同的人权观念,也证明了欧美数据人权叙事的虚伪,即强调隐私权和言论自由旨在弱化数据的经济属性及其指向的发展权,欧美数据法的溢出效应扩大了数字鸿沟。从这个意义上讲,多元均衡的数据人权观念是我国协调内国法域外效力和提升国际治理影响力的起点,也是完善国内立法和构建国际治理叙事的基础。

(一)数据的隐私属性与域外数据隐私法的影响

技术发展使政府机构甚至小型企业可以相对轻松地收集、存储和传输前所未有规模的个人信息,这导致公众担忧监控社会最终秘密到来。对这些发展的回应最早源自西方,西方从20世纪60年代起便展开了关于数据保护和隐私权的讨论,到70年代,美国、法国和德国等相继颁布隐私保护立法。从各国立法来看,数据的隐私和人权属性认定与保护原则有着一致的基调和方向,但数字时代隐私权的解释和适用以及保护范围有明显差异。欧盟和美国在保护数据隐私的发展方面有着共同的历史,起步时间基本同步,共同推进了第一套个人数据隐私保护国际原则,即《保护指南》,但二者的数据隐私理念以及相关立法存在着较大的分歧。首先,虽然都始于对数据技术日益发展及其不当使用的担忧,但在如何适用及适用对象上很快便产生了分歧。欧洲国家认为适用对象应当包括私营部门,设立了专门的数据保护机构,并将此种认知纳入了2018年的《通用数据保护条例》^{[4]432}。而美国主张仅适用于公共部门,私营部门只受部门立法、自我规制以及法院判决的约束^{[5]357-358}。这是两种隐私文化的呈现,德国和法国强调隐私来自“尊严”概念,美国则认为其是追求自由的结果^{[6]1161}。基于自由主义传统和互联网企业对全球数据的控制实力,美国始终采取开放和自由的互联网政策,提倡企业和行业自我规制足以保护个人,也就是美国隐私话语中所称的“消费者权利”^{[7]78}。其次,经历了二战的欧洲比美国更注重保护个人数据,欧盟自视为隐私和数据保护的先驱,隐私权和数据保护权是《欧盟基本权利宪章》和其他文件承认的两项不同的人权,建立在尊严、人格和信息自决等理念之上,虽然实践中欧盟仍然将数据保护权与隐私权相关联。而美国宪法上讨论的隐私是“大杂烩”,学理上一直没有明确、统一的隐私权概念^{[8]164-165},其将个人置于数据市场之中,任何人都可以自由地进行数据交换,法律主要是为了规制数据交易不公平、欺骗和其他市场失灵^{[9]137}。但过度夸大欧美之间的差异意义不大。如前所述,美国许多州致力于以欧盟为标杆提高数据隐私保护水准,以州为单位展开统一性立法。这种现象起源于环境法领域的“加州效应”^①,相应地,欧盟数据法的域外影响被称为“布鲁塞尔效应”^{[10]153}。虽存在差异,但仍有一些根本性共识值得注意:一是多个国际人权文件将隐私权认定为人权,如《世界人权宣言》和《公民权利和政治权利国际公约》。这些文件通过时虽没有设想个人数据的普遍获取和商业化趋势,但是2013年以来多

① 加州效应指加利福尼亚州先进、严格的环境保护标准被美国其他州效仿。参见 Vogel D., *Trading Up: Consumer and Environmental Regulation in a Global Economy*, Cambridge: Harvard University Press, 1995, p. 286。

个联合国大会决议表明,隐私权适用于数字隐私保护^①,确证了将数据保护置于国际人权法背景下的趋势。二是法理上虽不完全相同,但个人信息(数据)与隐私权的内涵接近。一般认为隐私权比数据保护的价值取向范围更为宽泛,体现为独处等一系列权利^{[11]93}。隐私权更多针对公共机关不干涉和通过法律保护个人的理念,数据保护权则面向个人、企业等更多的主体^{[12]226}。但隐私权最近的发展则既涉及私人亦强调国家的义务,如今数据保护权和隐私权之间存在很大的重叠^{[13]313}。三是虽然数据保护权越来越独立,但仍被视为与隐私权内涵一致且关系密切的权利。在审理个人数据保护案件时,欧盟法院亦会对数据披露可能影响个人隐私展开讨论,对个人是否被识别或可识别以及隐私是否受到侵害给予足够的重视^{[14]43}。美国虽然强调数据隐私主要基于消费者利益而展开,但实践中从未割裂数据与隐私的关联链条^{[15]816}。故而,域外法通常将隐私、个人信息、数据保护同等对待和使用。

网络空间的物理无边界性使得国内数据法均有域外效力。即使高度实行数据本地化的国家,亦无法回避网络空间的物理无边界特征,跨境数据流动的规制必然产生“规范溢出”效果。基于保护理念和水准、立法技术和经济地位等原因,只有美国和欧盟的法律产生了明显的域外影响。无论是数字经济的规模还是规制的既往经验,欧盟明显无法与美国和中国相比,却似乎在为全球确立规则。《通用数据保护条例》要求只有具有保护充足性(adequate level of protection)的国家或地区才能传输欧盟个人信息。对充足性认定设置了诸多要求,要求输入国应具有与欧盟同等的数据保护水平,个别企业进行数据跨境传输时须符合标准合同条款以及应具备的自治规范等。这限制了企业处理个人数据的方式,并有“侵略性的域外适用效应”^{[16]378}。许多国家和企业均难以达到欧盟数据法的要求,一些国家通过立法、修法或者调整市场实践适应欧盟的要求^{[17]769}。如美国监管机构不断要求企业加强数据隐私的自我规制,企业也游说美国立法者制定相关的法律^{[18]4}。在美国联邦缺乏统一立法的情况下,许多州正在分析欧盟数据法的要素以制定基于州的数据隐私保护规范。2018年,加利福尼亚州颁行《消费者隐私法》,这项法律被描述为赋予加州消费者类似于欧洲人权利的第一步。美国则以“长臂管辖”达到国内法外溢效果,联邦法(如2018年的《澄清境外数据的合法使用法案》)和某些州已经或正在通过的数据隐私法都有意强化域外效力。

(二)完善中国数据隐私保护与人权叙事

《中华人民共和国个人信息保护法》(以下简称《个人信息保护法》)采取了区隔主义的做法,即区分隐私、信息、数据并割裂了它们之间应有的关联,主要目标在于促进数据产业发展,存在忽视权利保障的可能性。在中国语境下,隐私、信息、数据存在一定的模糊关系,这在《个人信息保护法》颁布前后的法律规范、司法裁判和学理讨论层面均有表现^{[19]86-88}。立法借鉴了哲学与情报学等学科领域中形成的“数据—信息—知识—智慧”的信息链理论以及数据、信息区分的理论^②。立法上的清晰无法替代实践中隐私、信息、数据三者之间的纠葛,反而更添新的问题^{[20]42}。对此,首先要客观地认知数据和信息的区隔。现实中数据与信息并不存在绝对的界限,从数据到信息是数据不断变得有序、不断得到验证的过程,信息可能成为再次进行数据处理过程中的数据。两者究竟是并列抑或包含关系取决于语境,关注从数据到信息的连续过程及其关联才是切中肯綮的做法。其次,无论是隐

① UN General Assembly Resolutions, The Right to Privacy in the Digital Time, A/RES/68/167, 18 December 2013; A/RES/69/166, 18 December 2014; A/RES/71/199, 19 December 2016; A/RES/73/179, 17 December 2018; A/RES/75/176, 16 December 2020; A/RES/77/211, 5 January 2023.

② 有学者明确指出,信息、数据在信息学意义上的可分性不等于在法学上的可分性。参见彭诚信、杨思益《论数据、信息与隐私的权利层次与体系建构》,载《西北工业大学学报(社会科学版)》2020年第2期,第79-89页;霍政欣、陈静《论司法对国际商事仲裁的介入限度——以〈反外国制裁法〉第12条为中心》,载《商业经济与管理》2024年第7期,第75-86页。

私、信息与数据的区隔,还是数据安全与个人信息保护机制的设计,均应以对个人的隐私和自由保护为起点。通常认为数据本身并无意义,但是数据也包含并非个人信息的数据或信息,收集数据正是为了形成信息,并围绕用户个人来展开市场运营^①。基于此,学理上虽然强调它们之间的差异,但是域外立法、实践和学术研究并未将数据、信息进行区隔,一般均有综合考量。数据治理的国际谈判与对话特别强调个人信息保护(数据保护、隐私保障)。对国际趋势的把握与国内隐私保护水准的提升密不可分。欧盟数据法之所以能够对域外产生重要的影响,关键在于以基本权利保护为出发点和目标。因此,中国应进一步完善个人信息保护法律规范,注重隐私、信息、数据之间的关联,将隐私权和个人信息保护确立为基本权利,既重视数据产业发展,也关注个人权利保障。唯有如此,才能够使他国(特别是欧美国家)承认中国个人信息保护水准具有基本权利保护的权属,进而提升与中国商谈跨境数据流动国际规则的意愿,进而提升我国有关法律的域外效应和国际话语权。

构建我国数据人权叙事须警惕欧美数据人权的片面和虚伪,回应在全球持续引起普遍关注的话题,即如何弥补发展中国家与发达国家之间不断拉大的数字鸿沟并降低数据的殖民主义风险。其一,欧美强调数据人权属性并未弱化数据的安全化趋势。“后斯诺登”时代,国家安全考量超越个人权利与自由屡见不鲜。例如,2020年以来,美国基于所谓的国家安全威胁,针对TikTok采取通过多个行政命令、法案等密集型举措进行打压、制裁和禁止^②,罔顾这些举措对言论表达自由的限制与侵犯。美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰等禁止在5G网络中使用中国华为设备亦是基于所谓的国家安全关切超越权利保护的考量。其二,一些域外学者认为中国立法视数据隐私为信息安全问题,而非人权问题^{[21]103},这忽略了不同国家的人权保护重点和顺序差异。传统的集体主义和秩序优先文化造就中国公民普遍较低的隐私关切。有观点认为中国法律对个人权利的有限保护和庞大的人口基数是中国数字经济快速发展的原因^{[22]970}。换言之,美西方的人权攻击目的是打击中国数字经济的国际竞争优势。其三,数字鸿沟和数据殖民主义证明,20世纪90年代的人权亚洲价值论^③在数字时代依旧有重要意义。欧美利用人权保护道德高地和规则主导弱化或消解数据的商业价值和经济属性,遏制其他国家的发展空间,恶化不对等发展,企图再度形成竞争优势和数字霸权。美国主导的贸易协定以促进数据自由流动为核心理念,强调个人在数字产品和服务中的选择自由,约束国家对数据流动的限制。欧盟强调个人数据和保护隐私的基本人权属性,主张高保护标准有助于建立数字经济信任和促进贸易发展。相较于发达国家,发展中国家更为重视发展权而非政治权利,强调数字能力建设对于促进数字经济和数字贸易发展的意义。发达国家为维护技术研发和产业先发优势,限制、拒绝共享基础成果,致使很多发展中国家面临基础设施不足、技术落后和能力缺失等数字鸿沟问题。受制于监管知识、经验和技术的匮乏,发展中国家明知约束流动可能违反国际法,仍出于发展考量采取此类措施,这是部分数字贸易壁垒的产生根源。

多元的数据人权有助于破解欧美对中国数字经济的围堵和数据法的偏见,也有助于推进数据全球治理的均衡探索。中国秉持机会均等的发展权价值理念,以弥合数字鸿沟,推动数字发展成果

① 基于隐私、个人信息与数据在数字时代的复杂关联,有观点强调设计型隐私保护和政府规制的重要性,以实现技术与法律的有效互动。参见高秦伟《数字时代设计型规制的理念及其展开》,载《现代法学》2025年第3期,第162-178页。

② Addressing the Threat Posed by TikTok and Taking Additional Steps to Address the National Emergency with Respect to the Information and Communications Technology and Services Supply Chain, Exec. Order No. 13, 942. Executive Order on Preventing Access to Americans' Bulk Sensitive Personal Data and United States Government-Related Data by Countries of Concern, Exec. Order No. 14, 117, 28 February 2024. Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, H.R.7521, 6 March 2024.

③ 人权亚洲价值观是20世纪90年代讨论最热烈的国际人权话题。从亚洲文化不同于西方个人主义传统的集体主义传统出发,人权亚洲价值观的核心内容是以人权的特殊性或曰相对性回应普遍性,偏重集体权利而不是个人权利,强调发展权作为人权的不可或缺性。

更多、更公平惠及全世界^①。数字经济的可持续发展符合国际社会的共同长远利益,推进发展中国家数字经济发展并非发达国家的单方施舍,所有参与弥合数字鸿沟的国家也终将享受弥合后带来的市场机遇。中国应团结广大发展中国家,作为发达国家和发展中国家的沟通媒介,推进国际社会对数字鸿沟和数字霸权的认识并对其进行防范、遏制,避免挤压本国产业发展空间和削弱国际话语权。创设针对发展中国家的技术援助和转让机制、能力建设支持以及灵活的规制例外安排,推进WTO和有关贸易协定对于缩小数字鸿沟的作用^{[23]143-151}。例如,与美欧主导的数字贸易规则相比,东盟在RCEP中规定了更为灵活的合法公共政策,明确实施公共政策的必要性由缔约方决定,以宽松的例外安排留下了政策调整和自主规制的空间。RCEP第12章“电子商务”专门规定了“通过电子手段跨境传输信息”条款,强调并尊重“每个缔约方可能对通过电子手段传输信息有自己的监管要求”,“缔约方不得阻止相关方为开展业务而跨境电子传输信息”。

三、国家安全关切:数据国际治理的关键

早期数据国际治理的重点是平衡个人隐私保护与互联网经济发展,近年还需应对国家安全关切,人权保护和国家安全关切是各国确立数据主权的最大动因。数字经济领域的国家安全议题存在不同的认知。有一种判断认为经济不应考虑国家安全因素,否则会威胁各国相互依存和经济全球化,另有观点主张国家安全内涵不断扩张,经济与安全不可避免地交织在一起,必须予以关注^{[24]11-12}。实践中,因国家安全而对跨境数据流动采取措施已经成为常态。然而,数据保护如何与国家安全相关联、国家安全和跨境数据流动限制措施之间的逻辑关系却鲜有讨论。对于前者,国家安全概念的泛化成了国际趋势,数据安全确实可能威胁国家安全,企业收集个人数据越来越被认为关涉国家安全。对于后者仅有一些研究认为,通过数据流动限制措施确保国家安全不仅构成贸易壁垒,而且在很大程度上是无效的^{[25]45-48}。首先,以安全为由的数据本地化要求增加了企业在不同国家复制服务器/系统的成本,合规要求的地域差异使得数字产品供应商更难采用一流的安全标准和做法,阻碍了企业减少网络延迟以及检测潜在网络风险能力的提升。其次,流动限制最终会提高数据在特定服务器的集中度,使其更容易受到网络攻击。最后,只要各国与全球网络保持连接,数据就很容易受到网络攻击,而本地化无法消除这些风险。因此,国家安全需要在国家主张与全球治理中达到平衡,需要在国内和国际层面以法治原则和方式加以拘束,谨慎界定数据安全以避免一律划归为国家安全问题并滥用国家安全例外。

(一)从数据安全到国家安全

安全概念最早作为技术问题而出现,又因技术发展产生了根本性的变化,从技术问题走向与知识产权、平等、隐私等价值并驾齐驱甚至颇有超越这些价值的趋势。这种趋势使得安全概念的内涵变得愈发扑朔迷离。如何评估安全,评估标准是否有道德基础,安全是否值得追求,皆值得讨论。从最早的计算机安全、计算机系统安全到最近的网络安全、网络空间安全以及数据安全的提法,都与国家安全有着密切关联。从技术角度而言,计算机安全以及系统安全包括了三个层面:保密性、完整性和可用性,侧重于保护计算机系统及其用户免受攻击威胁。网络以及网络空间安全包括应对利用网络化的计算机从事反社会、破坏、颠覆活动而造成的威胁;对关键性社会基础设施的威胁;对网络本身的各种威胁(从无法正常运作至完全崩溃)。而数据安全更会影响到社会的各个部门和各个领域,对数据安全进行监管是推进数据国际治理的关键。

^① 参见《中国关于全球数字治理有关问题的立场(就制定“全球数字契约”向联合国提交的意见)》,2024年1月15日, https://www.mfa.gov.cn/web/wjbm_673085/zjzg_673183/jks_674633/zclc_674645/qt_674659/202305/t20230525_11083602.shtml, 2025年1月15日。

在早期,欧盟和美国的数据保护一词很少关乎国家安全。一般认为,数据保护一词包含了数据隐私(企业如何收集、使用和披露个人信息)和数据安全(企业如何保护个人信息免受未经授权的访问或使用,以及如何应对未经授权的访问或使用)。虽然两者各有侧重,但是数据立法越来越将数据安全与数据保护统一到单一领域之内^{[26]2232}。数据立法主要围绕个人数据或者个人信息而展开权利、义务架构,这种出发点决定了立法的基础在于保护个人,而欧盟的《通用数据保护条例》和美国加利福尼亚州颁行的《消费者隐私法》表明了一种将隐私和数据、数据保护和数据安全完全关联并纳入统一立法倡议的趋势^{[27]9}。目前这种趋势成为世界主要的立法模式,影响力较大。因为数据保护领域多次出现严重的安全事件,立法上将数据隐私、数据安全与国家安全建立关系是对现实的回应。如2018年,某酒店发现黑客访问了3.83亿位客人的信息,可以揭示客人的旅行习惯、日程安排和护照数据等,这是非常危险的信息收集和监控,美国将此次入侵提升为国家安全问题。剑桥分析、斯诺登事件后,个人信息保护与国家安全的关联度进一步提高。但问题在于基于国家安全,政府可以要求企业等组织共享数据,使得传统执法和反恐怖/情报行动之间的区别变得模糊。数据的流动性导致一国国家安全机构有权在全球范围内展开监视活动;各国的隐私保护程度不同,政府通过多种形式规避宪法对公民隐私的保障;一些国家以国家安全为由展开的监控程序不甚透明,且无对其的充分审查等。因此,数字时代的国家安全关切有扩大至数据隐私的正当性。但国家安全只有在法治的原则下运行才能真正保护数据隐私和数据安全,为防止出现国家安全政治化应用和过度拓展而引起的企业恐慌和对个人隐私的忽视,应重视监管公权力的考量。

(二)数据隐私与国家安全的关联

自民族国家出现以来,国家安全一直是国际关系中的首要问题。问题在于国家安全概念历史悠久,却很少被定义^{[28]1579}。有效定义缺位无助于实施一个维护国家安全的监管框架,不利于清晰判定数据隐私是否以及如何符合国家安全概念的内涵和要求。信息隐私、数据安全和国家安全之间的关联从未像目前这般重要、紧密。基于正当的国家安全理由,国家有权加强网络与数据安全以免受他国造成的威胁,但以国家安全为由的诸多措施存在阻碍数据流动的负面影响,尤其是没有证据表明禁止和限制数据流动的正当性。在全球层面就适当的监管政策以及私人 and 公共数据收集处理的边界和限制达成一致,需要思考数据隐私或者敏感个人信息是否为国家安全或者仅是其一部分、数据保护政策与监管安全化是维护国家安全的正当举措还是确保本国利益的单边借口。

作为互联网大国,美国一贯标榜重自由、轻监管,但对网络和数据中的国家安全问题关注最早,其数据与安全的关联最为复杂,监管最为严格。早在2003年,布什政府出台的《网络空间安全国家战略》就将网络安全确定为国家安全的关键问题。2009年,奥巴马政府将个人信息数据安全纳入国家安全范畴。1950年,《国防生产法案》授权外国投资委员会审查外国投资是否存在潜在的国家安全风险;2018年,《外国投资风险审查现代法案》扩大了授权,外国投资委员会有权审查任何“维护或收集美国公民的敏感个人数据”的外国投资^{[29]106},不仅包括针对美国企业控制权的外国收购和合并,还包括特殊关注企业的非控制权或访问权,即关键技术、关键基础设施和敏感个人数据。对于数据相关业务,该法案规定外国投资委员会必须审查有关外国投资是否“维护或收集美国公民的敏感个人数据,这些数据可能会被以侵害国家安全的方式利用”。许多批评认为这个法案的“敏感个人数据”过于宽泛^{[30]645}。“敏感个人数据”最终被界定为两类信息:(1)可识别数据,由满足某些要求的美国企业收集的以及在规定法律中的十类数据中可明确识别的数据;(2)个人基因测试的结果,包括基因测序数据,只要这些结果构成可识别的数据。但这一界定依然复杂且极为广泛,易致国家安全泛化。敏感个人数据是隐私的一部分,但并非所有隐私问题均涉及国家安全,数据隐私可能只是间接地影响国家安全,并不或不完全属于国家安全领域^{[31]673}。从美国的操作来看,敏感个人数据

多与国家安全直接挂钩。如数据公司 PatientsLikeMe 的业务是将患者与其他健康状况相似的人联系起来,被美国外国投资委员会强迫寻找美国买家,并剥离中国基因研究公司 iCarbonX 的 1 亿美元股份。事实上,这家公司拥有不超过 83 万人的 2 800 种健康状况数据,没有达到法律要求的 100 万人阈值,这些信息并不构成遗传信息。

美国和欧盟、中国在数据安全领域持续产生分歧和争端,这个过程的意义在于反思个人数据在什么程度和范围内与国家安全相关联以及如何规制。在数据保护政策和监控日益安全化的背景下,欧盟法院十年来第二次推翻欧美数据传输协议,对欧盟与美国之间个人数据传输的未来、跨大西洋经济以及国际数据治理均有着重大的影响^[32]⁴。2020 年,欧盟法院 Schrems II 案基于 WTO 安全例外的自裁决性质,以《欧盟基本权利宪章》作为充足性认定标准,判定美国监控计划的宽广范围和法律救济措施缺位构成根本性问题,推翻了欧美数据传输协议的法律基础^①。欧盟以《欧盟基本权利宪章》确立更高的个人权利保护标准并强加给第三国,被批评为过度监管^[33]¹⁷⁸⁻¹⁸⁰。判决也昭示了欧盟和美国在数据保护和隐私理念方面长期存在的分歧,在保护个人数据方法上的根本差异,体现了欧盟对数据安全化的强烈担忧。但重新平衡大西洋两岸数据共享安排的合作前景不容乐观,2023 年 7 月,欧美达成第三份数据传输协议,核心内容与前两个版本没有本质差异,下一轮争端在所难免。美国针对 TikTok 采取的密集举措、2021 年的《对抗性平台防范法案》和 2024 年的第 14117 号总统行政令创建美国人数据对华跨境传输审查机制的核心逻辑是中国正在建立美国公民数据库,这将带来国家安全风险。实际上,TikTok 收集和处理的 data 过于琐碎,无助于从事间谍活动或寻找进入美国系统的“后门”,对中国政府而言意义不大。正如 2020 年终止总统行政命令生效的法院判决所说,TikTok 数据传输“不涉及任何有价值的个人通信”^②。美国企业也存在着类似的操作,其他国家可以通过其他方式获取这些美国个人数据。国家安全担忧与其说是针对中国利用平台收集美国个人信息的潜在能力,不如说是中国数据跨境流动增长速度和企业发展引发了对中国经济影响力提升的恐惧。美国将数据隐私宽泛地纳入国家安全审查范围,没有考虑具体的数据范畴、审查方法及成本,简单地将数据隐私与国家安全直接关联的方法难以令人信服^[34]¹³³。

(三) 国家安全泛化和例外滥用的法治约束

1947 年签署的《关税与贸易总协定》(GATT)第 21 条的国家安全例外规则明确,成员方在关涉核材料、军火贸易以及战时或国际关系中的其他紧急情况下为保护核心安全利益所采取的必需行动免除 GATT 项下义务。而且,国家安全属于“自我判断”事项,即成员方有自行判定国家安全例外的裁量权,国家安全例外不受任何形式的外部审查,主要通过外交谈判和相互克制加以实现。此后,在 WTO 内外,包括《服务贸易总协定》(GATS)和《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)在内的贸易和投资协定大多设定了类似的条款,允许各国逃避承诺,只要愿意承担相应的政治和经济代价。这是在普通经济行为与国家安全之间划定简单的界限,使得国家安全与经济全球化成为两个独立的领域。冷战结束后国家安全政策的发展使得国家安全和国际经济秩序的交集持续扩大,各国发现国家安全例外能够凌驾于国际经济秩序之上而满足本国的需求。21 世纪在非传统国家安全主张之下,国家安全与国际经济秩序紧密地交织在一起,越来越多的安全措施完全置于法律秩序之外,突破了经济和安全二者界分的原有平衡,滥用例外措施破坏了以规则为基础的国际经济秩序。网络世界的国家安全举措已经成为日常操作,数据跨境传输易受阻碍,更需要法治的约束。

第一,鉴于任由自我决断和司法(准司法)裁决均不可行,应当将政治和法律手段结合起来解决

① European Union Court of Justice, Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Limited and Maximilian Schrems, Case C-311/18, Judgement of 16 July 2020.

② TikTok v. Trump, 507 F. Supp. 3rd 92, 98 (D.D.C. 2020).

国际经贸领域的国家安全争端。许多国家确立或修订外商投资国家安全审查机制,有些以国家安全的名义限制或者禁止外国投资,外国投资者频频利用争端解决机制挑战东道国的国家安全决定^[35]¹⁰。GATT时期的国家安全例外措施争端大多通过外交方式解决,专家小组坚持第21条的自裁决性质^①。近年提交给WTO争端解决机构的此类争端大幅增加,2018年以来有十余起。2019年,专家小组在俄罗斯过境案中首次试图解决贸易和安全的二分法冲突,明确对安全例外的措施有审查权^②。其为安全例外确立了两步式框架解释方法:(1)客观地审查“战争”“紧急情况”或其他援引依据的存在;(2)成员方是否谨慎地判定相关措施对于保护其基本安全利益的必要性。在中国等诉美国钢铝产品案中,专家小组从第21条的文本解释出发,结合GATT谈判中各方的立场和主张等,判定美国采取的措施不符合安全例外条款的“核心国家安全利益”规定,强调“国际关系紧急情况”应指向与战争对国际关系的影响程度具有可比性的严峻情形。这个审查权的启用限制了成员方对国家安全的任意性扩大解释,否定了GATT第21条的自我审查性并植入嵌入性框架,围绕相关紧急措施对维护安全利益的必要性,基于《维也纳条约法公约》条约解释方法进行“善意原则”检查。虽然审查权能够产生约束例外滥用的效果,但明显超越GATT导致其合法性存疑,削弱了WTO争端解决机构的权威性。审查权的行使仍不可避免地涉及实质性审查,一旦WTO、国际投资争端解决中心(ICSID)等国际争端解决机构对国家安全措施展开比例原则审查,便是对一国的国家安全利益判断进行二次评估。审查国内行政机关的决定表面上可能遏制国家安全的扩张,但很难成为条约文本加以正当化,也很难制约国家运作。为在稳定和灵活之间提供预期的平衡,解决国家安全例外主义和司法监督之间要么全有要么全无的冲突,有必要构建在国际贸易、投资争端之间和其间出现的“影子政治”^③,利用“去司法化”方案将安全措施的部分成本内化,使政策灵活性的需要与将国家安全纳入法律秩序的重要性相协调,以促进国际经济秩序与国家安全机制之间的相互承认和学习^[36]²⁵。具体而言,可以成立专业化的委员会或者监察专员制度^[37]⁴⁵⁴,也可以成立国家安全措施委员会为解决争端作出有益的贡献^[38]¹⁴⁷²。

第二,WTO和有关贸易、投资协定中设置和细化数字贸易国家安全例外条款极其必要,也势必艰难,中国应有破有立地推进。首先,破除美国在国家安全界定与监管中内外有别的逻辑悖论。美国贸易法充斥着实施国家安全限制和壁垒的特权^[39]¹⁰⁹⁷。在监管数据相关业务的外国投资中,滥用安全例外措施最为频繁、恶劣。与国内泛化规制和严格监管形成鲜明反差的是,对外坚持自由贸易凌驾于国家安全的立场。为了防止缔约方利用自裁决采取单方面行动或为数据本地化寻找借口,在美国的坚持下,USMCA禁止将本地化作为成员方境内开展数据业务的前提,CPTPP的前身《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)曾否定以国家安全为由限制数据流动,只能援引一般例外,且无权自行判断。这反映了美国希冀尽可能多地使数据流入本国,再纳入本国监管的利益诉求^[40]¹⁷⁹。其次,现有协定虽然大多沿承GATT的国家安全例外理念,明确保护目标是核心安全利益,但宽严口径不一。核心安全利益的具体判定、例外措施合理性和必需性的解释、自裁决属性和合法性国际审查实践有待观察。例如美国退出后,CPTPP第29条确立了安全例外,缺少“成员方认为必要”字样指向的自行判断,也没有排除第三方审查,而RCEP的数字贸易安全例外肯定了自裁决性质,为各方留下了灵活调整政策和采取措施的空间。中国应当在维护国家安全和推动数字贸易自由的双重前提下,推进国家安全例外条款的中国方案,审慎对待其自裁决性质,以渐进方法实现例外条款的细化。

① 如1985年尼加拉瓜诉美国案,专家小组虽然认定美国采取的措施对于保护任何基本安全利益不是必要的,最终仍将国家安全内涵和相关措施交给主权国家自行阐明和管理,无论这些行动在第21条下是否实际有效。Panel Report, United States Trade Measures Affecting Nicaragua, L/6053, 13 October 1986, paras. 5.1-5.17。

② Panel Report, Russia—Measures Concerning Traffic in Transit, WTO Doc. WT/DS512/R, 5 April 2019。

③ 影子政治(shadow politics)指整合官方和非官方主体共同推进某项倡议或维护利益的二元结构。

中国相关法律中的数据安全已突破技术认知,覆盖范围广泛且事关国家安全。但有关法律以及国家互联网信息办公室、国家数据局等机构的职能表述尚未明确数据安全与国家安全的边界和交集。应明确治理边界和细化监管要求,给予公民和企业恰当的数据自决权,避免以国家安全统领个人隐私和商业秘密的倾向。

第三,将国内立法和行政程序作为数据国际治理的探索性补充。相比在国际层面对安全措施设计整齐划一的程序机制,为与安全有关的国内行政程序制定具体的标准更具有可行性。在此基础上,可通过软法文件,为特定类型的安全举措和程序制定标准,在国家之间与国际层面形成一种互补性框架。首先,在网络和数据治理中,许多国家跟美国一样,行政权力扩展导致三权分立与制衡失灵,立法机构对以紧急状态和国家安全为由的诸多行政举措不加约束甚至支持,司法只在被动情况下发挥有限作用,有必要完善立法和规范行政程序。其次,国内立法细化数据治理的国家安全边界。各国数据立法大多关涉国家安全,但“国家安全”一词往往是论说的出发点,具体含义变幻莫测且不乏“想当然”。美国2001年以来颁行《外国情报监视法》《美国爱国者法案》《存储通信法案》等多部法律文件,目的在于防止恐怖主义和加强公共安全,但破坏了隐私保护的原有状态,大幅提升了私营部门运行的不可预见性和合规成本。《美国爱国者法案》授权相关机关调取第三方记录,对域外个人和企业产生了重大影响。不受限制的权力以及滥用国家安全的做法使美国在与科技平台打交道时愈发显现出独裁模式。鉴于数据隐私联邦立法是近年美国国会的热议话题,中国和欧盟可以联合推促形成统一的个人信息保护法,即便难以撼动美国数据监管理念和推动结构性变革,也力争明确国家安全范围,使行政权力更多受到国会和法院的监督。最后,反对滥用安全措施的最佳场所在于国家安全机关本身,即行政程序的法治运作。各国在多大程度上能够提供一个透明和公开的程序,值得反思。有些国家对数据传输的行政性安全审查标准极为模糊,如美国有关钢铁和铝进出口对国家安全影响的调查就极其不透明。利用他国国内法规则使国家安全转向程序性审查,依据国内行政法的原则展开此种做法是对国际组织试图遏制国家安全扩张在国内的配合。这种利用其他国家国内法程序性限制的做法在欧洲极为常见,使得行政程序的问题变得极为重要^{[41]40-41}。

四、数据主权的弹性观念

在国内治理的快速发展下,数字主权、数据主权和网络主权概念应运而生^{[42]112-122}。一般认为,数字主权大体包括网络主权和数据主权两个方面,前者偏重载体,后者偏重内容^{[43]47-48}。越来越多的国家意识到数据主权的重要性,纷纷努力确保和加大对数据收集、存储、分析等环节的管控力度,或者采取分级分类等方式严格管理重要数据出口,或通过本地化的措施避免关键数据外流导致国内发展、数据安全、国家安全受到威胁。用主权概念证明以保护人权和维护安全为由限制和禁止数据流动的正当性,为数字环境治理提供基础,反映了各国维护主权的决心,也使得数据国际治理的格局更加复杂多变。数据业已成为推动经济社会发展的新动能,纳入主权范畴加以保护和管控实属必然,但数据的特性和互联网的迅猛发展给数据主权的实现带来挑战。除了曾经存在过的“政府间信息局”^①,尚没有国际组织对国家主权和数据自由两个相互竞争的原则加以调和。中国应当以弹性的方式实现数据主权,既重视国家利益和域外管辖权,也关注数据主权的相互依赖性和数据的人权属性。

^① 政府间信息局(Intergovernmental Bureau for Informatics)是一些发展中国家和少数发达国家(如意大利、法国、西班牙等)于1978年成立的国际组织,曾就跨境数据流动提出系列建议,1987年解散。

(一)数据本地化与域外管辖权:进攻、防守抑或攻守兼备

由于尚未达成统一的数据管辖国际协作安排,在数据主权观念下,各国各自解决数据跨境流动的监管权力分配。美国、欧盟、中国、俄罗斯等均制定相应的本地化和域外管辖权战略与规则,既对本国数据业务主体有强制效果,亦对存储于境外的数据拥有支配能力。美国和欧盟等奉行进攻型战略,美国主要通过“长臂管辖”的物理延伸不断扩张跨境数据执法权,而欧盟则依靠人权保护标准的价值观拓展。最具代表性的“长臂管辖”是2018年美国的《澄清境外数据的合法使用法案》,将数据管辖要求扩大到位于其他国家的数据,数据控制者有义务遵循美国的强制命令向其提供。美欧的进攻型战略更加适宜于超越属地管辖的网络空间,是向更为灵活的域外管辖权迈进。中国、俄罗斯、印度等为代表的国家坚持防守型战略,通过数据本地化解决法律适用和本地执法问题。同时,美国也有本地化要求,适用于为国防部工作的云计算服务提供商存储或传输联邦数据。但是美国本地化措施的激增在一定程度上扰乱了数字贸易,与网络空间物理无边界现实背道而驰^{[44]195}。

政府扩大监管范围至网络空间是必然趋势,攻防态势表明了确立数据治理基本规范和网络国际监管框架的重要性。20世纪90年代末至21世纪初,学界有关数据本地化和域外管辖权的讨论增多^{[45]1199[46]1365},过去几年对立声音锐增,这与政府和公众对全球化的日益不安以及在互联网上维护国家边界的愿望有很大关系^{[47]2089}。如果缺乏基本规范和监管框架,那么批评和认可本身都很难抵消数据治理中各类“主义”的恶化趋势。第一,确立认同主权差异的互联网基本规范,以保持互联网治理制度的合理运行。在各国主张数据和网络主权之时,一国只能通过实际控制互联网实现监管目标,政策制定者越是推动全球主义,就越是加速朝着另一个方向发展。因此,解决数据主权冲突的前提是尊重他国数据主权,域外管辖权应与尊重法律体系多样性的必要性相协调,否则最终会因其他管辖区的司法裁决而失效。互联网治理的争论不应只停留在互联网应当是国际化的、全球化的还是分裂的,而要扩展到如何基于相互尊重治理反映和适应主权差异的互联网。应重回传统的“国际礼让”原则解决外国法适用问题,在合理限度内尊重一国有关国家安全和个人权利保护的优先事项。第二,认同数据主权差异的核心在于互操作性,在不同的权利保护方法和立场中寻找共识,确立基本国际规范。这是提升数据权利保护标准的首选途径,是化解数据保护“帝国主义”和数字“主权主义”之间日益紧张局势的最佳途径。数字时代的隐私保护越来越暴露出不同法律体系在境外实施数据保护之间的紧张关系。不同法律体系声称对数据拥有管辖权,被称为数字“主权主义”的动态发展,同时,一种被称为数据保护“帝国主义”的动态发展正在兴起,即对其他国家的控制逐渐成为各国相互效仿的做法。第三,各国应当诚实地解释强化数据主权的动机,以区分权利保护与保护主义。各国限制数据传输举措的公开动机不同。欧盟基于美国情报机构广泛的电子间谍活动以及互联网公司侵犯隐私等现象强化数据权利保护,许多数据本地化举措主要是为促进本国数字经济发展而设;一些数据本地化措施的动机是传统的保护主义,如印度尼西亚将数据本地化措施作为政府纠正贸易赤字和改善基础设施战略的一部分;还有一些则是民族国家试图将数据置于当地立法和执法之下。这反映了不同法律体系的宪法价值观和文化价值观、不同国家的数字经济诉求,不能简单地全部视为保护主义,而要详细调查数据民族主义和保护主义对言论自由和隐私保护等权利的影响。虽然欧盟强调限制多是针对特定数据处理风险而设,并非保护主义^{[48]101-120},但滥用数据保护法以促进商业利益的可能也是存在的。美国应当认真对待与在线个人有关的权利保护,而不是假设所有数据本地化措施均有保护主义色彩,欧盟也应超越基于欧盟法律的自我认知,更多地关注数据保护措施是否在实践中带来更大的保护效力。

对中国而言,首先,在鼓励数据跨境流动原则和保护基本权利共识下,细化域外管辖权以维护数据主权。在尊重他国数据主权和行使域外管辖权之间取得平衡,进一步澄清国内法的域外效力,

细化对侵犯国家安全、数据主权、公共利益行为行使域外管辖的情形。其次,可采取基本原则加例外条款的模式平衡数据保护和数据自由的紧张关系,细化分级分类管理和提升数据安全的执法能力,实现安全与发展相平衡的规制导向。考虑到各国普遍存在本地化做法,问题的关键不在于能否采取本地化措施,而在于本地化措施的正当性依据。因此,应禁止数据的绝对本地化,对数据安全措施作出一定的创新,根据不同类型和水平的数据确定不同类型的本地化措施。同时,应建立公平合理的域外数据调取机制,允许外国政府或个人请求调取存储在中国的数据。最后,借鉴欧盟“阻断法案”,从源头上否认和阻却美国“长臂管辖”的域外效力。1996年,欧盟出台的《免受第三国立法及由此产生行动之域外影响的保护法案》以法律的形式遏制美国日益严重的“长臂管辖”干涉,保障欧盟企业和个人免受第三国法律的域外适用。2018年,为了帮助欧盟企业应对美国制裁伊朗,欧盟又重启更新该法案,基于违反国际法明确否认第三国法律的效力。英国、澳大利亚、加拿大亦有类似立法。此种做法对中国具有借鉴意义。2021年中国商务部颁行《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》,其性质虽系部门规章但适用范围较广泛,旨在补齐制度短板以阻断域外管辖权的不当适用。考虑到其规则内容过于简单,操作性有待实践检验,有必要在细化完善后提升立法层级。

(二)弹性数据主权的中国策略

数据国际治理经历了主权国家合作框架初步形成、数据主权下政策调整、双边或区域协定三个发展阶段,这个演进过程彰显了数据主权的弹性特点。首先,对数据的管辖从以领土为重心转向域外发展,但数据主权并不适用属地和域外二分,也并不能总是从领土主权中引申出来,这挑战了以领土作为国际法中物理空间定义认识论的基础作用。完全以领土为中心并非正确的前进方向^{[49]224}。其次,网络新疆域在公、私二分的范围之外运作,将属地作为空间定义确立数据治理原则忽视了代码、算法和私人行为者的重要作用。代码的重要性突显了代码编写者和公司决策者在确定如何配置数据传输以及数据建立何种关系方面的必要性。算法可被视为执行各种形态的全球治理形式,创造了新的法律关系^{[50]127}。在重新配置管辖、保护隐私和维护国家安全议题之中,非国家实体特别是企业发挥着强大的作用,因为它们决定收集和利用哪些人的数据、在哪些管辖区域存储数据,以及如何调解跨境的数据纠纷。最后,数据跨境流动下私人、公共权力的新“地域”摆脱了传统的领土概念,但又需要与主权建立联系。数据治理中主权和管辖权在一定程度上是通过技术来实践和实现的,但又不仅仅是技术决策,因为涉及大量的利益分配和政治利害关系,例如哪些法律规则适用、数据跨境传输的方式和速度如何,以及哪些国家从科技公司在其境内运营和存储数据中获得经济利益。简言之,数据领域的国际法在以国家为中心的框架之外创造新的关联配置^[51]。与其将主权理论化为国家权力的上升或下降,将其作为国际法中权力和权威的中心,以威慑的方式将技术理论化为与法律竞争的权力来源,不如考虑公私行为体的治理权限及权力如何相互协作和相互塑造。这可以通过法律构建主权的弹性来实现,这种弹性体现在权力对公司、代码和算法编写者、其他数据治理行为者和代理人的分配和启用中,以及行为者和代理人如何重塑法律规则、主权和管辖权。数据的权力和治理是多重的和偶然的,行使这些权力须避免社会问题重新政治化和完全纳入主权权威,最终以弹性建构的主权权力成就治理功能。

数据主权的弹性实现思路有助于中国完善国内立法和治理体系,在回应欧美之时,形成数据国际治理的中国方案。在实现策略层面,我国需要注意以下问题:第一,数据国际治理涉及的个人隐私保护、数字贸易、国家安全和主权等问题都需要衔接国内法与国际法。目前探讨较多的是个人信息保护所承载的价值追求所引发的国家间利益之争(包括基本权利和经济利益)、国别法律的域外适用(美欧各有特点,中国怎么办)、国际规则确立的问题(美欧起步较早且极为积极,中国怎么办)。中国要重视数据主权的坚持,但亦要保持灵活,欧美倚重的自下而上治理模式有灵活优势,值得借

鉴。因此,中国应重视完善国内相关立法,构建自上而下和自下而上兼容并重的治理模式,立足本国基础对接域外。第二,在国际治理层面,欧美维持各自的特点和优势,推进数据国际规制协调的努力导致国际治理体系的部落化和碎片化。中国应该在不断扩大数字经济市场规模的基础上,积极拓展国际合作以推广中国规制标准和治理模式。以缩小数字鸿沟和抵制数据霸权为切入点,应对“数字地缘政治”竞争,提升国际话语权。充分鼓励企业走向海外,借由企业将中国数据治理理念和规范体系从东盟推向“一带一路”共建国家,深化中国与更多国家在数字经济、信息基础设施、技术研发等领域的全方位交流与合作,使更多国家与中国政府一起为推动数据全球治理作出努力。第三,改变目前中国在数据监管国际合作上仍以理念层面为主、实践层面参与度较低的被动局面,在共商共建共享基础上为世界提供中国方案。积极加入国际数据规则体系,增进跨境数据流动领域的战略互信,借助双边、多边和区域等层面谈判尝试构建符合中国利益的国际规则,最终推动在WTO、联合国和其他相关组织框架下达成规制数据跨境流动的国际规则。应当充分利用硬法、软法综合之治确保国际规则的灵活性,既可以平衡各种目标和各方诉求,也可以对国际与国内变化的不确定性作出及时有效的回应。

五、结 语

当前的数据跨境流动比以往任何时候都要普遍和重要。尽管各国数据规范有显著趋同之势,但仍然存在尚未得到充分重视和解决的人权、安全和主权的理念偏差与关联互动问题,导致共识性的全球合作愈加匮乏。欧美片面的人权叙事忽视了发展权,引发了数字鸿沟和数据殖民主义并使其日益加剧。欧美的数据安全、数据主权的主张和做法存在明显的不自治,美国表面上提倡自由流动理念,实质上是通过国家安全与数据主权的内外差别确保自身的国际竞争优势;欧盟则以高保护标准的侵略性域外效应和保护主义倾向的数据主权确保和提升自身的国际影响力。为回应欧美,其他国家更加看重国家安全和数据主权的工具价值,通过限制和禁止数据跨境流动以维护本国利益。因此,深入理解个人隐私、国家安全和数据主权的耦合关系,以弹性差序协调推进数据的自由流转,才能突破双边、区域贸易协定的制约,回到WTO以及更广泛的国际组织框架下展开有效的合作。相比欧美,中国的数据治理理念更为多元均衡,但理念建构与规则叙事的国际影响相对单薄,在数据国际治理发展的十字路口和申请加入CPTPP和DEPA的关键期,如何定位和完善自身的数据监管并拓展域外影响,是统筹推进国内法治和涉外法治的重点工作。

[参 考 文 献]

- [1] Novotny E. J., "Transborder data flows: a bibliography," *Stanford Journal of International Studies*, Vol. 16 (1980), pp. 181-199.
- [2] 单文华、邓娜:《欧美跨境数据流动规制:冲突、协调与借鉴——基于欧盟法院“隐私盾”无效案的考察》,《西安交通大学学报(社会科学版)》2021年第5期,第94-103页。
- [3] Kirby M., "Legal aspects of transborder data flows," *Computer Law Journal*, Vol. 11, No. 2 (1991), pp. 233-245.
- [4] Raab C. & Szekely I., "Data protection authorities and information technology," *Computer Law and Security Review*, Vol. 33, No. 4 (2017), pp. 421-433.
- [5] Brookman J., "Protecting privacy in an era of weakening regulation," *Harvard Law and Policy Review*, Vol. 9, No. 4 (2015), pp. 355-374.
- [6] Whitman J. Q., "The two western cultures of privacy: dignity versus liberty," *The Yale Law Journal*, Vol. 113,

- No. 6 (2004), pp. 1151-1221.
- [7] Regan P. M., *Legislating Privacy: Technology, Social Values, and Public Policy*, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1995.
- [8] Büyüksagis E., "Towards a transatlantic concept of data privacy," *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Vol. 30, No. 1 (2019), pp. 139-221.
- [9] Schwartz P. M. & Peifer K. N., "Transatlantic data privacy law," *The Georgetown Law Journal*, Vol. 106, No. 1 (2017), pp. 115-179.
- [10] Bradford A., *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*, Oxford: Oxford University Press, 2020.
- [11] Tzanou M., "Data protection as a fundamental right next to privacy? 'reconstructing' a not so new right," *International Data Privacy Law*, Vol. 3, No. 2 (2013), pp. 88-99.
- [12] Kokott J. & Sobotta C., "The distinction between privacy and data protection in the jurisprudence of the CJEU and the ECtHR," *International Data Privacy Law*, Vol. 3, No. 4 (2013), pp. 222-228.
- [13] Kuner C., "An international legal framework for data protection: issues and prospects," *Computer Law and Security Law Review*, Vol. 25, No. 4 (2009), pp. 307-317.
- [14] Kovalenko Y., "The right to privacy and protection of personal data: emerging trends and implications for development in jurisprudence of European Court of Human Rights," *Masaryk University Journal of Law and Technology*, Vol. 16, No. 1 (2022), pp. 37-58.
- [15] Schwartz P. M., "Global data privacy: the EU way," *New York University Law Review*, Vol. 94 (2019), pp. 771-818.
- [16] Rustad M. L. & Koenig T. H., "Towards a global data privacy standard," *Florida Law Review*, Vol. 71, No. 2 (2019), pp. 365-453.
- [17] Mattoo A. & Meltzer J. P., "International data flows and privacy: the conflict and its resolution," *Journal of International Economic Law*, Vol. 21, No. 4 (2018), pp. 769-789.
- [18] Shaffer G., "Globalization and social protection: the impact of EU and international rules in the ratcheting up of U.S. privacy standards," *Yale Journal of International Law*, Vol. 25, No. 1 (2000), pp. 1-109.
- [19] 韩旭至:《信息权利范畴的模糊性使用及其后果——基于对信息、数据混用的分析》,《华东政法大学学报》2020年第1期,第85-96页。
- [20] 朱晓峰:《数字时代离线权民法保护的解释路径》,《环球法律评论》2023年第3期,第24-42页。
- [21] Ann-Lee J., "Hacking into China's cybersecurity law," *Wake Forest Law Review*, Vol. 53, No. 1 (2018), pp. 99-104.
- [22] Shtub T. G. & Gal M. S., "The competitive effects of China's legal data regime," *Journal of Competition Law & Economics*, Vol. 18, No. 4 (2022), pp. 936-970.
- [23] Mishra N., *International Trade Law and Global Data Governance: Aligning Perspectives and Practices*, Oxford: Hart Publishing, 2024.
- [24] Chin Y. & Zhao J., "Governing cross-border data flows: international trade agreements and their limits," *Laws*, Vol. 11, No. 4 (2022), pp. 1-22.
- [25] Meltzer J., "Governing digital trade," *World Trade Review*, Vol. 18, No. S1 (2019), pp. 23-48.
- [26] Hartzog W. & Solove D. J., "The scope and potential of FTC data protection," *The George Washington Law Review*, Vol. 83, No. 6 (2015), pp. 2230-2300.
- [27] Burt A. & Geer D., "Flat light: data protection for the disoriented, from policy to practice," 2018-11-29, <https://www.lawfaremedia.org/article/flat-light-data-protection-disoriented-policy-practice>, 2024-09-04.
- [28] Donahue L. K., "The limits of national security," *American Criminal Law Review*, Vol. 48, No. 4 (2011), pp. 1573-1756.
- [29] Boyd R. H., "FIRMA: buy American products, or bye American progress?" *Wake Forest Journal of Business and Intellectual Property Law*, Vol. 19, No. 2 (2019), pp. 103-123.
- [30] Feder A., "A bull in a China shop: how CFIUS made TikTok a national security problem," *Cardozo International and Comparative Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2022), pp. 627-645.
- [31] Westbrook A. D., "Securing the nation or entrenching the board? the evolution of CFIUS review of corporate

- acquisitions,” *Marquette Law Review*, Vol. 102, No. 3 (2019), pp. 643-673.
- [32] Zalnieriute M., “Data transfers after Schrems II : the EU-US disagreements over data privacy and national security,” *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 55, No. 1 (2022), pp. 1-45.
- [33] 杨帆：《后“Schrems II 案”时期欧盟数据跨境流动法律监管的演进及我国的因应》，《环球法律评论》2022年第1期，第178-192页。
- [34] Faison A., “TikTok might stop: why the IEEPA cannot regulate personal data privacy and the need for a comprehensive solution,” *Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy Sidebar*, Vol. 16 (2021), pp. 115-145.
- [35] Wehrle F. & Pohl J., “Investment policies related to national security: a survey of country practices,” 2016-06-14, <https://doi.org/10.1787/5jlwrrf038nx-en>, 2024-09-04.
- [36] 吴晓丹：《数字贸易国际治理：重塑 WTO 的中心化地位》，《国际商务（对外经济贸易大学学报）》2025年第2期，第11-31页。
- [37] Alter K. J., Hafner-Burton E. & Helfer L. R., “Theorizing the judicialization of international relations,” *International Studies Quarterly*, Vol. 63, No. 3 (2019), pp. 449-463.
- [38] Lester S. & Zhu H., “A proposal for ‘rebalancing’ to deal with ‘national security’ trade restrictions,” *Fordham International Law Journal*, Vol. 42, No. 5 (2019), pp. 1451-1474.
- [39] Claussen K., “Trade’s security exceptionalism,” *Stanford Law Review*, Vol. 72, No. 5 (2020), pp. 1097-1164.
- [40] 时业伟：《跨境数据流动中的国际贸易规则：规制、兼容与发展》，《比较法研究》2020年第4期，第173-184页。
- [41] Chachko E., “Foreign affairs in court: lessons from CJEU targeted sanctions jurisprudence,” *The Yale Journal of International Law*, Vol. 44, No. 1 (2019), pp. 2-51.
- [42] de Jong-Chen J., “Data sovereignty, cybersecurity, and challenges for globalization,” *Georgetown Journal of International Affairs*, Vol. 16 (2015), pp. 112-122.
- [43] 廖凡：《数字主权与全球数字治理》，《暨南学报（哲学社会科学版）》2024年第7期，第47-60页。
- [44] Peng S. & Liu H., “The legality of data residency requirements: how can the trans-Pacific partnership help?” *Journal of World Trade*, Vol. 51, No. 2 (2017), pp. 183-204.
- [45] Goldsmith J. L., “Against cyberanarchy,” *University of Chicago Law Review*, Vol. 65, No. 4 (1998), pp. 1199-1250.
- [46] Post D. G., “Against ‘against cyberanarchy’,” *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 17, No. 4 (2002), pp. 1365-1387.
- [47] Kuner C., “Data nationalism and its discontents,” *Emory Law Journal Online*, Vol. 64 (2015), pp. 2089-2098.
- [48] Kuner C., *Transborder Data Flows and Data Privacy Law*, Oxford: Oxford University Press, 2013.
- [49] Hildebrandt M., “Extraterritorial jurisdiction to enforce in cyberspace? Bodin, Schmitt, Grotius in cyberspace,” *University of Toronto Law Journal*, Vol. 63, No. 2 (2013), pp. 196-224.
- [50] Johns F. E., “Global governance through the pairing of list and algorithm,” *Environment and Planning D: Society and Space*, Vol. 34 (2016), pp. 126-149.
- [51] Johns F. E., “Data territories: changing architectures of association in international law,” in Kuijter M. & Werner W. (eds.), *Netherlands Yearbook of International Law: The Changing Nature of Territoriality in International Law*, vol. 47, The Hague: T.M.C. Asser Press, 2017, pp. 107-129.

**Global Governance of Cross-border Data Flow:
Interconnection and Differentiated Order of Human Rights,
National Security and Sovereignty**

Wu Xiaodan

(Law Faculty, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China)

Abstract: The international regulation of cross-border data flow is not merely within the scope of digital trade law, but a primary constituent element of the international legal order for data and cyberspace. In the

context of development suspension of global rules, the divergent regulation among states and bilateral, regional trade agreements has created an overlapping, interactive, and competitive governing situation, and the insufficient, fragmented and differentiated rules constitute non-tariff trade barriers of cross-border data flow and give rise to constant transitional disputes and conflicts, which has enlarged the risk of data colonialism, data imperialism, data nationalism and data protectionism. The essential causing roots are the interrelated and complex relations among the three core concepts, i.e., human rights, national security and sovereignty, and the vital differences and competition in the relevant notion values, policy orientation and regulation approaches. There are different definitions for personal data and divergences surrounding the right to privacy and right to development. The biased emphasis of the US and EU laws on civil rights, particularly the freedom of speech undermines the economic dimension of data and the related right to development issues, and the overspill effect of their domestic laws has enlarged the digital divide. Therefore, strengthening the implementation of right to development should be the concern of international legal order for data and cyberspace. The extension of national security scope and the strategic importance of data has promoted the issue of data and cyber security to be the concerns of national security and triggered the misuses of national security exceptional rules for national security in trade and investment agreements. The impact of cyberspace on sovereignty has furthered the policy and practice differences and conflict in data regulation, especially with respect to the issues of the long-arm jurisdiction, extraterritorial effect of data rights protection and universal practice of localization requirements and measures. Therefore, there is an imperative need to abolish the current set-pattern of focusing on domestic data law and international economic order and the technical separation of domestic law and international law, and integrally and interrelatedly rethink the core concepts of human rights, national security and sovereignty. A flexible and differentiated order diffusing the vast differences regarding these three concepts and the corresponding fragmented and divergent regulation values and methods could promote the construction of a coordinated, uniform global data governing framework. Regulation competition has become a major part of international competition. As the most advanced form of international competition, regulation competition lays the foundation for coordinating international rules and constructing a universally accepted data governing framework. The data laws of the European Union, the United States and China are the primary source of competition for formulating global governing framework, which presents the opportunity for coordinating international rules and constructing global legal order. International data regulation originates from the interaction of domestic law and international law, which is also the key elements for the United States and the European Union to shape and influence international rules. As for China, the core tasks are demolishing and responding to the biased, double-standards narratives of human rights, national security and sovereignty in data regulation; improving domestic regulations values and regulatory rules; proposing international law narratives based on domestic needs and international cooperation. China's proposal for data international regulation shall be built upon the flexibility of data and cyber sovereignty, focusing on national security and equity protection of personal information and aiming at the promotion of free cross-border data flow.

Key words: cross-border data flow; privacy protection; national security; data sovereignty; data localization; global governance data

